

1500305-85.2022.8.26.0535
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: LARISSA BONI VALIERIS
Comarca: Mairiporã
Foro: Foro de Mairiporã
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 11/07/2022

...
Incumbe salientar, igualmente, que o tráfico é crime de perigo abstrato e formal, de forma que não se cogita na produção de resultado material, pois o legislador deu ênfase na proteção do bem jurídico vago da saúde pública, ou seja, "o crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mairiporã

2ª Vara JUDICIAL

Rua Doutor José Adriano Marrey Jr., nº 780 - Centro - CEP: 07600-225 - Mairiporã - SP

Telefone: (11) 4419-5636 - E-mail: mairipora2@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500305-85.2022.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500305-85.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE AUGUSTO EMILIO ROSSINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Larissa Boni Valieris

Vistos.

ALEXANDRE AUGUSTO EMILIO ROSSINI, já qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 04 de Fevereiro de 2022, pela manhã, na Rua Alzira Ferreira Campos, próximo ao imóvel de nº 135, Jardim Fernão Dias, nesta cidade e Comarca de Mairiporã, o réu, teria oferecido e guardado, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína e 12 (doze) papelotes contendo crack, para distribuição, comercialização e entrega a terceiro (Auto de Exibição e Apreensão às fls.12/13; Laudo de Constatação às fls.17/19). Conforme a denúncia (fls.02/03) e, segundo o apurado, o réu, hipoteticamente, resolveu realizar comércio ilícito de drogas. Para tanto, ofereceu à terceiros e guardou, em um quadro de energia elétrica, dentro de uma sacola, as substâncias ilícitas acima referidas, todas embaladas individualmente e prontas para a distribuição. Na ocasião, guardas municipais trafegavam pelo local e observaram o réu oferecendo algo, de forma velada, para terceira pessoa, em atividade típica de tráfico de drogas, momento que resolveram realizar a abordagem. Ao perceber a aproximação dos guardas municipais, o denunciado, em tese, tentou esconder a sacola com drogas dentro de um quadro de luz, porém os agentes públicos conseguiram abordá-lo e apreender o objeto. Dentro da sacola, teoricamente, foram encontradas as drogas acima mencionadas. Asseverou, a denúncia, que o réu foi conduzido à unidade policial, onde confirmou a propriedade das substâncias e que as

drogas eram destinadas ao comércio espúrio.

O réu foi preso em flagrante às fls.04.

O Ministério Público às fls.36/37 requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

A Defensoria Pública às fls.41/42 pugnou pela concessão da liberdade provisória ao réu.

O réu, por intermédio de sua defensora nomeada, requereu às fls.43/46 a concessão de liberdade provisória sem fiança, em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Não obstante, pleiteou pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, caso seja conveniente.

Decisão às fls.47/51 em que converteu a prisão em flagrante em preventiva, considerando a gravidade em concreto do fato delituoso, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais do réu, com base nos artigos 282, § 6º, e artigos 310, inciso II e 312, todos do Código de Processo Penal. Mandado de Prisão às fls.58/59.

Regularmente notificado (fls.96), o réu apresentou defesa prévia às fls.91/93, pugnando pela rejeição da denúncia, desclassificando o crime para o artigo 28, da Lei de Drogas. Não obstante, requereu o afastamento de agravantes e causas de aumentos de pena e arrolou, ao final, testemunha.

O Ministério Público às fls.100/103 requereu o recebimento da denúncia.

Decisão às fls.104/105 em que recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento.

Em audiência de instrução e julgamento (fls.120/121), foram ouvidas as testemunhas, em seguida, interrogado o réu e, por derradeiro, concedeu-se a liberdade provisória ao acusado. Alvará de Soltura às fls.124/125.

Em alegações finais, o d. representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, para condenar o réu nos exatos termos da denúncia.

Quanto à dosimetria da pena, não vislumbrou circunstâncias que justifiquem a exasperação da pena base; na segunda fase, presente a atenuante da confissão, porém inviável sua aplicação, porquanto a pena nesta etapa não pode ser reduzida aquém do mínimo legal; na terceira fase, aplicável o benefício do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. No que toca ao regime prisional, opinou pela fixação do semiaberto e entendeu incabível a conversão por restritivas de direitos, todavia presente circunstâncias que possibilitam que o réu recorra em liberdade.

A d. defesa, por sua vez, reiterou a manifestação ministerial, no que tange ao regime semiaberto e o benefício de recorrer em liberdade.

Certidão de Antecedentes Criminais às fls.26/27 e Folha de Antecedentes às fls.28/29 e 83/86.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, ausente, ainda, quaisquer causas de nulidade que tenham ensejado prejuízo ao réu, passo ao exame do mérito.

Nesse passo, de pronto, anoto que a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls.04), Termo de Depoimento (fls.05/07), Interrogatório (fls.08), Boletim de Ocorrência (fls.09/11), Auto de Exibição e Apreensão (fls.12/13), Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (cocaína - massa líquida: 2,31g, 1,81g e 14,64g - fls.17/19), Auto de Qualificação (fls.20), Nota de Culpa (fls.23), Laudo de Lesão Corporal Cautelar (fls.34/35), Depósito Judicial (fls.63), Relatório Final (fls.65/66), Exame Químico-Toxicológico - Laudo Definitivo (cocaína - fls.87/88), bem como pelas provas orais colhidas. Logo, é certo que restou devidamente comprovado o objeto material "droga", indicado no tipo penal do caso vertente, que prevê crime não transeunte, sendo regularmente apreciados os seus vestígios em prova tarifada pelo legislador (artigo 158, do Código de Processo Penal c.c. artigo 50, §§ 1º e 2º, da Lei nº 11.343/06).

Sobreleva notar que tal substância encontra-se expressamente prevista na Portaria 344/98 e Resolução nº 104 da ANVISA, amoldando-se perfeitamente à definição legal

de droga (artigo 1º, Sú., da LD).

De outra banda, verifico que a autoria restou delineada, ante a consonância dos elementos colhidos na fase inquisitorial com aqueles produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não bastasse, o réu, em seu interrogatório, confessou a prática do delito, e explanou que, próximo de sua residência, efetuou a venda de entorpecentes; visava sustentar sua família, especialmente seus filhos, todavia entende que não justifica os fatos; está arrependido; há um ponto de venda de drogas nas imediações de sua residência e avistava todos os dias um rapaz descendo, enquanto se dirigia até o CRAS em busca de serviço; a assistente social o ajudava com os currículos, pois não conseguia emprego; fazia trabalhos informais para a manutenção da sua casa; o rapaz que via, ofereceu 55 (cinquenta e cinco) pinos de cocaína e 12 (doze) pedras de crack, prometendo que lhe daria R\$ 120,00 (cento e vinte reais), lhe dizendo, ainda, que depois de 3 horas retornaria naquele mesmo quadro de luz onde havia deixado as drogas para pegar o dinheiro; era o seu primeiro dia, começou a vender os entorpecentes às 9h e às 10h45min os guardas da GCM o abordaram, na Rua Alzira Ferreira Campos; é usuário de drogas.

A par disso, a testemunha Cristiano Oliveira Guimarães, Guarda Municipal, em juízo, narrou que, estavam em patrulhamento e passaram próximo ao "escadão" (sic), instante em que viu o réu passar algo para outro rapaz; quando ele notou a viatura, tentou esconder algo dentro de um quadro de luz; o abordaram; o réu dispensou porções de crack e no local em que havia escondido, encontraram uma sacolinha com entorpecentes; a outra pessoa foi identificada e encaminhada para o departamento de polícia; no bolso do réu havia R\$ 121,00 (cento e vinte e um reais) e alguns centavos; a cocaína e o crack estavam embalados individualmente, em porções; o réu confessou o delito e disse que estava vendendo drogas para sustentar o seu filho recém-nascido; o local dos fatos é conhecido por ponto de venda de drogas.

Igualmente, a testemunha Donizete José Brito Nunes, Guarda Municipal, declarou que, estavam em patrulhamento preventivo pelo Bairro Fernão Dias; avistaram o réu e suspeitaram que ele estava passando algo para um rapaz; quando eles o visualizaram, o réu tentou esconder algo dentro de um quadro de energia; constataram, posteriormente, o produto ilícito; o denunciado afirmou que as drogas eram suas; o local é conhecido pela venda de entorpecentes; havia valor em espécie com o réu; as drogas estavam em porções de venda; o réu confessou que estava vendendo drogas para sustentar seus filhos.

Cumpra salientar que os policiais e guardas municipais são funcionários públicos sujeitos aos princípios, aos deveres e às prerrogativas, inclusive quanto à prática de atos administrativos inerentes à Administração Pública. O policial ou guarda municipal não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório.

Nesse ponto, vale notar que "o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que, aliás, não se afere no caso em tela.

Como se vê, a prova é robusta o suficiente para embasar uma condenação, pois hialino que o réu praticou os núcleos "vender", "oferecer", "guardar", "entregar a consumo", previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tipo misto alternativo, sendo certo que houve a apreensão de quantidade de droga suficiente para lesionar o bem jurídico tutelado, e já devidamente fracionada para venda, ainda mais porque não comprovou que exercia qualquer atividade remunerada à época dos fatos, donde se vê que sua conduta causou grande dano à saúde pública, além do fortalecimento de

organizações paraestatais, violando o bem jurídico tutelado pela norma penal. Outrossim, extrai-se o seu intuito comercial do próprio local em que concretizada a abordagem, qual seja, ponto de mercancia de drogas.

Incumbe salientar, igualmente, que o tráfico é crime de perigo abstrato e formal, de forma que não se cogita na produção de resultado material, pois o legislador deu ênfase na proteção do bem jurídico vago da saúde pública, ou seja, "o crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT776/663). Logo, ainda nesta hipótese, restaria consumado o crime.

Por fim, nota-se que o acusado detinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Em observância ao princípio da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria, e é adotado pelo Código Penal no artigo 68, passo à dosimetria da pena, anotando, desde já, a primariedade do agente.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atenta aos requisitos constantes do artigo 59, do Código Penal e ao disposto no artigo 42, da Lei 11.343/2006, observo que ausentes circunstâncias que justificam a exasperação da pena. Destarte, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

De outro banda, incide a atenuante da confissão, imperiosa a incidência do disposto no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Todavia, a pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ), assim sendo, mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e possível a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da LD, dado que o réu é primário, de bons antecedentes e não restou cabalmente demonstrado que se dedicava às atividades criminosas, tampouco que integrava organização criminosa. Logo, diminuo a pena em 2/3, tornando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa. Assim, "Tratando-se de réu primário e não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a inserção do paciente em grupo criminoso de maior risco social, a atuação armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de refino da droga, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é medida que se impõe." (STJ, AgRg no HC 705.950/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

Ausentes elementos que denotam a capacidade econômica do réu, fixo o valor unitário do dia-multa no piso legal.

Diante do "quantum" da pena aplicada, o regime inicial será o aberto, em exegese ao artigo 33, do Código Penal. Possível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo, por ser medida mais adequada para absorção da terapêutica penal. Justifica-se a substituição por duas restritivas de direitos em razão do lapso temporal da pena substituída.

Cabível a substituição da pena, nos termos do artigo 44, do Código Penal, não há que se falar em suspensão condicional da pena (artigo 77, do Código Penal).

Ante o exposto, e por tudo o que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ALEXANDRE AUGUSTO EMILIO ROSSINI à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor mínimo legal (artigo 49, "caput", e parágrafos, do Código Penal), por restar incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo a prestação de serviços à comunidade pelo tempo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de um salário mínimo.

O réu poderá recorrer em liberdade, diante da fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto e substituição da pena corporal por restritivas de

direito, nos termos da fundamentação.

Ainda, atendendo a nova redação do artigo 387, § 2º, Código Processual Penal, dada pela Lei 12.736/12, deixo de proceder à detração da pena, ante a inconstitucionalidade do dispositivo, por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, uma vez somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Ademais, ainda que assim não fosse, observo que, embora se possa saber o tempo que o réu permaneceu custodiado, não dispõe esta magistrada de informações seguras sobre a satisfação dos demais requisitos para a detração da pena ou eventual progressão de regime, o que reforça a tese de que a avaliação dos requisitos indispensáveis à concessão desses benefícios somente é possível pelo Juízo da Execução da pena, nada se podendo fazer neste momento do processo. Custas e demais despesas pelo réu, ressalvada hipótese de gratuidade processual (artigo 804, do Código Processual Penal).

Como a quantia apreendida e o bem apreendido estão intrinsecamente vinculados à prática delitativa - fruto da mercancia da droga-, declaro seu perdimento em favor da União, devendo ser transferida para o FUNAD.

Oficie-se à autoridade policial, autorizando a incineração das drogas, se ainda não ocorreu, devendo o fato ser certificado nos autos (artigo 72, da LD).

Após o trânsito em julgado:

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Expeça-se guia de execução penal.

Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

Mairiporã, 08 de Julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA